

1500367-24.2022.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/06/2022
... 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-24.2022.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500367-24.2022.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049738/2022 - 03º D.P. AMERICANA, 23153208 - 03º D.P. AMERICANA, 335/22/346 - 03º D.P. AMERICANA, 2049738 - 03º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KLEBER BRITO DOS SANTOS
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

KLEBER BRITO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 05 (cinco) quilos de fiação elétrica, pertencentes à vítima H.T.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 138/140).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 159/161).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls. 173/174).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 180/181), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado.

E, o Doutor Defensor do réu requereu a absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente o afastamento das qualificados e fixação de pena mínima e regime mais brando (fls. 185/189).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 02/04 e 09/11, e laudo de fls. 122/131.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, “De la Apreciación de las Pruebas”, tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950,

pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A vítima Helbert, ouvida em Juízo, informou que essa casa estava aguardando venda ou locação, e foi comunicado, pelo pessoal da imobiliária acerca da subtração. Disse, ainda, que dirigiu-se ao local, onde constatou que as tomadas foram danificadas e foi retirada a fiação da casa. Acredita que o réu adentrou o imóvel pulando o muro. Por fim, soube que ele foi apreendido pouco após, e teve a fiação devolvida, mas ela não é passível de ser utilizada, tendo um prejuízo aproximado de mil e quinhentos reais.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter o réu.

Os guardas municipais esclareceram que foram informados de um possível furto de residência em andamento, visto por um vizinho. Disseram, ainda, que em patrulhamento visualizaram um indivíduo de características semelhantes. Declararam, também, que efetuaram a abordagem, momento em que o réu tentou evadir-se, mas acabou por ser detido. Em revista, na mochila localizaram os objetos subtraídos.

Indagado, o réu alegou ser usuário de drogas e utilizar-se de pequenos furtos. Em contato com o proprietário, este reconheceu os fios. Por fim, o réu foi encaminhado ao hospital e à Delegacia, e foi solicitada a perícia ao local.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Não procedem, ainda, as alegações da defesa quanto à divergência dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos

oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

O réu, ouvido em Juízo, negou a prática do delito, alegando que passou por uma obra, e ganhou a fiação de um rapaz. Disse ser morador de rua e sobrevive pedindo e recolhendo reciclagem.

O réu apresenta "álibi" (ganhou a fiação em uma obra), sem, no entanto, comprová-lo. A alegação não comprovada de álibi é também indicio que milita em desfavor do réu. De acordo com a doutrina:

"No terreno do processo penal há uma forma de defesa que é exclusiva e passou a ser conhecida como o 'álibi'.

Álibi, etimologicamente, significa em outra parte, em outro local. A princípio consistia uma exceção oferecida pelo acusado mediante a qual afirmava que, ao momento do crime, estaria em outro local, portanto, impossível sua participação. Com o decorrer do tempo ampliou-se seu significado, passando a representar toda alegação fática feita pelo acusado visando demonstrar a impossibilidade material de ter participado do crime.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constituiu uma exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração.

'Imperativa é a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta um álibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso' (JTACrim 54:204). Completando: JTACrim, 47:165, 33:334 E 22:77." (CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.18)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e Materialidade comprovadas. Palavra guarda municipal. Validade Precedentes. Ademais, o acusado foi encontrados na posse do objeto receptado. Incabível a alegação de insuficiência probatória. Álibi não comprovado. Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...). APELO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 0008542-14.2014.8.26.0229, da em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Silmar Fernandes, Data: 29/11/2018).

Estelionato – Vítima iludida e orientada a depositar valor na conta do réu para receber indenização judicial – Prova segura e coerente – Álibi do acusado fantasioso e não comprovado – Condenação mantida – Recurso provido em parte para adequação da pena, com reconhecimento da prescrição. (Apelação nº 0005053-20.2009.8.26.0495, da 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Alexandre Almeida, data: 01/12/2017).

PROVA - Invocação de alibi - Circunstância que resta indemonstrada - Formação de indício contra o réu - Entendimento:118 - Quem invoca alibi, para recusar a co-autoria, ou a participação em delito, não o provando, faz despontar indício de má justificação, a ser utilizado contra o réu. RJDTCRIM VOLUME 16
OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 214 RELATOR: - SÉRGIO PITOMBO

Há que se analisar que as declarações do réu são contrárias ao seu depoimento na Delegacia de Polícia (fls. 13), onde confirmou a subtração, o que, aliado aos depoimentos das demais testemunhas, torna carente de credibilidade sua negativa de autoria.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é o fato de que o réu já foi condenado pela prática de crime de contra o patrimônio o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTCRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: "A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO

VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

“O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal” (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito é inconteste. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133 RELATOR: - MARREY NETO

PROVA - Furto - Presença de indícios - Valor:182 - Sendo os crimes de furto praticados normalmente sem a presença de testemunhas, os indícios passam a ter valor relevante para a apuração da autoria. RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 324 RELATOR: - MESQUITA DE PAULA

Desta forma, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado relativo ao delito de furto, inclusive acerca das qualificadoras.

Ainda, as qualificadoras relativas à escalda e ao rompimento de obstáculo encontram-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 122/131, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Por fim, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 54/73) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-

base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. No mais, em se tratando de furto duplamente qualificado (escalada e rompimento de obstáculo), há maior reprovabilidade da conduta do acusado. Exaspero, por isso, a pena base na 1/4 (um quarto), delimitando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 54/73. Acrescento à pena base, portanto, 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Não é possível o reconhecimento do privilégio constante do § 2º, do artigo 155, do Código Penal em caso de furto qualificado. Além disso, para que o benefício fosse concedido, é requisito que o réu seja primário e portador de bons antecedentes. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. 2. No caso, um dos réus é reincidente e o valor da coisa subtraída, somado ao prejuízo suportado pela vítima para o conserto de sua residência em razão do arrombamento, não pode ser considerado pequeno para fins de reconhecimento do privilégio pleiteado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1511869/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

FURTO QUALIFICADO - Aplicação do privilégio - Impossibilidade:117 - É impossível a aplicação do privilégio ao furto qualificado, vez que o agente de tal delito representa maior soma de perigo para a sociedade, tanto que o Legislador Penal teve o cuidado de tratar do benefício antes das circunstâncias qualificadoras. RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 220 RELATOR: - THYRSO SILVA

Ademais, os antecedentes e reincidência do réu desaconselham a adoção de tal benefício.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado em razão de ser o réu reincidente, além do fato de que conta com circunstâncias judiciais desfavoráveis. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). IV - Com efeito, "é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo" (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/08/2018). Na hipótese em foco, nota-se o delineamento de elementos concretos para a imposição de regime mais gravoso - os maus antecedentes, a reincidência e outras duas condenações definitivas a indicar a reiteração delitiva -, não se restringido a fundamentação a considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu KLEBER BRITO DOS SANTOS à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

P. I. C.

Americana, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA